

1501594-36.2020.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... das investigações referentes ao tráfico de drogas registrado no RDO 1020/2020, desta unidade policial, onde constavam algumas anotações da contabilidade do tráfico e endereço onde poderia estar sendo armazenado mais drogas. Deslocando até o endereço acima citado em viatura descaracterizada com vidros escuros realizaram discreta campana. Neste período, junto com a equipe ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501594-36.2020.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501594-36.2020.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2242209/2020 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 13880109 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 1077/20/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2242209 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO COSTA BORELLI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ofereceu denúncia em face do réu DIEGO COSTA BORELLI, como incurso pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, e no artigo 34, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal. Narrou a denúncia que, no dia 30 de setembro de 2020, por volta das 13h00, na Rua Patrícia Lúcia de Souza, nº 129, Jardim Oliveira, nesta cidade e comarca, o réu, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes na massa líquida de 3.039g (três mil e trinta e nove gramas) de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", acondicionada em 04 (quatro) tabletes, na massa líquida de 13.420g (treze mil, quatrocentos e vinte gramas) de cocaína e em 95 (noventa e cinco) litros de lança perfume, sendo estas substâncias entorpecentes e que determinam dependência física

e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Constatou, ademais, que, nas circunstâncias de tempo e de local acima descritas, o réu, possuía e guardava instrumentos e objetos destinados à preparação de drogas, consistentes em 03 (três) balanças de precisão, 02 (duas) peneiras, 01 (um) liquidificador e invólucros plásticos e de vidro destinados a armazenar substâncias entorpecentes, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 110/111).

Notificado (fls. 145/146), o réu apresentou defesa preliminar às fls. 119/128. Em síntese, alegou a ilegalidade do flagrante, a consunção entre os crimes previstos no artigo 33 e 34, da Lei nº 11.343/2006. Requereu que a empresa SPTRAFO fosse oficiada para que disponibilizasse as imagens captadas por suas câmeras externas na data e horário aproximado dos fatos.

Petição reiterando o pedido de produção de prova (fls. 143/144).

A denúncia foi recebida no dia 01 de março de 2021, mesma oportunidade em que foi deferido o pedido feito pela Defesa quanto à produção de prova (às fls. 147/149). Petição da empresa SPTRAFO informando não ter as imagens requisitadas, tendo em vista que as gravações perduram por 30 dias apenas e que a empresa teve problemas técnicos com seu equipamento de câmeras no final do ano passado e passou por manutenção e substituição de peça (fls. 193/194).

Citação (fls. 207).

Realizada audiência de instrução e julgamento ocasião em que foram ouvidas quatro testemunhas, todos agentes públicos, e a companheira do réu, como informante. Em seguida, o réu foi interrogado. Ao final, a D. Representante do Ministério Público requereu que a Delegacia de Polícia fosse oficiada para apresentar o laudo químico-toxicológico do restante das drogas apreendidas (cocaína e maconha). A Defesa, por sua vez, requereu que o 1ª DP de Embu das Artes fosse oficiado para apresentar cópia do RDO nº 1020/2020 e do respectivo inquérito policial. Ambos pedidos foram deferidos, determinando-se seu cumprimento imediato (fls. 244/245).

Cumprida as diligências ora determinadas, sobrevieram memoriais escritos.

O Ministério Público postulou a procedência do pedido contido na denúncia com a condenação do acusado. Ao final fez considerações acerca da dosimetria da pena (fls. 278/299 e 427).

A Defesa advogou teses benéficas ao réu. Reafirmou a tese de nulidade em virtude de violação de domicílio do acusado, questionou acerca da idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais em juízo e argumentou que o depoimento da informante, Sra. Jessica, deve ser tido como o verdadeiro. Subsidiariamente, argumentou que o entendimento Superior Tribunal de Justiça se dá no sentido de que deve ser aplicado o princípio da consunção entre os crimes do artigo 33 e 34, da Lei de Drogas (fls. 303/316). Juntou documentos (fls. 317/339 e 428/432).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitativa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/02 e 10; boletim de ocorrência de nº 1077/2020 de fls. 03/06; boletim de ocorrência de nº 1020 de fls. 367/369 e 380/382; autos de exibição e apreensão de fls. 19/21 e 385 (este último referente às anotações para o tráfico apreendidas no bojo da investigação atinente ao boletim de ocorrência de nº 1020); laudos de constatação de fls. 36/38 e 251/253; laudos definitivo de fls. 189/191 (lança-perfume), 241/243 e 254/256 (maconha e cocaína); laudos de constatação dos objetos apreendidos de fls. 226/228, 229/232, 233/236, bem como pelos depoimentos colhidos durante a fase policial e instrução judicial.

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

Extrajudicialmente, a testemunha e policial civil João Charles Ferreira declarou "que nesta data dando continuidade das investigações referentes ao tráfico de drogas registrado no RDO 1020/2020, desta unidade policial, onde constavam algumas anotações da contabilidade do tráfico e endereço onde poderia estar sendo armazenado mais drogas. Deslocando até o endereço acima citado em viatura descaracterizada com vidros escuros realizaram discreta campana. Neste período, junto com a equipe observaram o indiciado chegando na casa com uma sacola. Desse modo resolveram abordar este indivíduo sendo então identificado como DIEGO COSTA BORELLI. Em revista pessoal foi encontrado na sacola que trazia consigo parte das

drogas. Indagado se tinha mais drogas, confessou que nos fundos da casa estavam guardadas mais drogas, levando os policiais até o local onde foram localizados 4 tabletes de maconha; porções de cocaína e 19 galões de 5 litros com substância líquida aparentando ser lança perfume. Questionado, o indiciado disse que as drogas pertencem a um indivíduo de vulgo "NENEM", não sabendo informar seu nome ou endereço e que apenas guardava as drogas. Diante disso, o indiciado e objetos foram apresentados a esta Delegacia para as providências de polícia judiciária." (fls. 11 e 359).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que no dia anterior já havia feito uma campana no local mas não viu o acusado. No dia seguinte visualizou o acusado chegando com uma sacola que continha droga e efetuou a sua prisão. O acusado disse que tinham mais drogas no interior da casa. As drogas estavam no quintal da casa. Não se recordou o que o acusado falou sobre as drogas. Pelo o que se recorda a esposa dele e o filho moravam lá, eles apareceram depois da ocorrência junto com o dono. O próprio proprietário confirmou que o acusado morava no local. Não se recordou quanto tempo demorou desde a apreensão das anotações que levaram ao endereço do acusado até o dia da diligência porque ficou apenas três meses naquela Delegacia. Pelo o que se recordava, o endereço da casa do acusado estava nas anotações apreendidas. Não houve pedido de mandado de busca e apreensão. A diligência foi feita pelo declarante e o policial Julio. No apoio estava o policial Marcos. Não se recordou se havia outro policial. Estavam com viatura descaracterizada. Posteriormente o Marcos chegou com viatura caracterizada. Não se recordou se era uma sacola ou mochila que o réu portava. Não se lembrou qual era a substância que estava dentro da sacola e nem o que réu falou sobre ela. Lembrou que ele disse sobre um tal de Nenê. Não tinha ninguém na casa do réu no momento da abordagem. Não se recordou se foi encontrado algum documento do réu na casa, mas ele mesmo disse que morava lá. A droga estava numa lavanderia. No momento em que encontraram a droga estava apenas o declarante e o policial Julio. Os demais policiais chegaram depois. Não se recordou se havia edícula na casa. O proprietário do imóvel morava em cima. Eles presenciaram o ocorrido depois que chegou a viatura descaracterizada. O proprietário não foi levado à Delegacia.

Extrajudicialmente, a testemunha e policial civil Julio Cesar Basetti declarou "que nesta data junto com a equipe de investigação, e dando continuidade das investigações referentes ao tráfico de drogas registrado no RDO 1020/2020, desta unidade policial, onde constavam algumas anotações da contabilidade do trafico e endereço onde poderia estar sendo armazenado mais drogas. Frente a estas informações deslocando até o local da investigação, estando em viatura descaracterizada com vidros escuros realizaram discreta campana. Neste período, observaram o indiciado chegando na casa com uma sacola. Desse modo resolveram abordar este indivíduo sendo então identificado como DIEGO COSTA BORELLI. Em revista pessoal foi encontrado na sacola que trazia consigo parte das drogas. Indagado se tinha mais drogas, confessou que nos fundo da casa estavam guardadas mais drogas, levando os policiais até o local onde foram localizados 4 tabletes de maconha; porções de cocaína e 19 galões de 5 litros com substância líquida aparentando ser lança perfume. Questionado, o indiciado disse que as drogas pertencem a um indivíduos de vulgo "NENEM", não sabendo informar seu nome ou endereço e que apenas guardava as drogas. Diante disso, o indiciado e objetos foram apresentados a esta Delegacia para dar continuidade aos trabalhos de polícia Judiciária." (fls. 12 e 360).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. O local parecia ser uma residência. Tinha pertences de criança. Ele morava com a esposa e o filho no local. Encontrou no local liquidificador e balança pelo o que se recorda. Tinha vários frascos de lança perfume e eppendorf pelo o que se recorda. Na época o declarante era lotado no 1º DP de Embu das Artes. O RDO 1020/2020 foi registrado nessa unidade. A ocorrência objeto destes autos não se deu no mesmo dia daquela registrada no RDO 1020/2020. A residência do acusado é em Taboão da Serra. Ele foi levado para Embu porque a investigação era daquela unidade. Participaram da prisão

do acusado os policiais arrolados no boletim de ocorrência. No RDO 1020/2020 não havia nada relacionado ao acusado, o que havia era uma anotação apreendida em que constava o endereço em que o acusado foi encontrado e preso. Não se recordou se essa anotação foi juntada nesses autos. Quando chegaram na residência o acusado estava chegando no imóvel. Com ele foram encontrados entorpecentes numa sacola. Salvo engano, na sacola tinha cocaína. Era uma sacola. Não soube precisar a quantidade de cocaína na sacola. Não se recordou o que o acusado falou sobre essa cocaína da sacola. Ele confessou que guardava entorpecente dentro da residência dele. Não tinha ninguém dentro da residência no momento da abordagem. As drogas estavam nos fundos da residência em uma área de lavanderia. A casa não possuía edícula. Não foi pedido mandado de busca e apreensão porque não tinham informações concretas até então. Foram até o local diligenciar nesse sentido. Inicialmente adentraram na residência o declarante e o policial Charles. Posteriormente chegaram os outros policiais que estavam no apoio numa rua próxima.

Extrajudicialmente, a testemunha e policial civil Marcos Roberto de Miranda declarou "que nesta data em apoio a equipe de investigação, e dando continuidade das investigações referentes ao tráfico de drogas registrado no RDO 1020/2020, desta unidade policial, onde constavam algumas anotações da contabilidade do tráfico e endereço onde poderia estar sendo armazenado mais drogas. Com estas informações e de comum acordo da equipe deslocando até o local da investigação, permanecendo em campanha com viatura descaracterizada com vidros escuros. Momento em que observaram o indiciado chegando na casa com uma sacola. Desse modo resolveram abordar este indivíduo sendo então identificado como DIEGO COSTA BORELLI. Em revista pessoal foi encontrado na sacola que trazia consigo parte das drogas. Indagado se tinha mais drogas, confessou que nos fundos da casa estavam guardadas mais drogas, levando os policiais até o local onde foram localizados 4 tablets de maconha; porções de cocaína e 19 galões de 5 litros com substância líquida aparentando ser lança perfume. Questionado, o indiciado disse que as drogas pertencem a um indivíduo de vulgo "NENEM", não sabendo informar seu nome ou endereço e que apenas guardava as drogas. Diante disso, o indiciado e objetos foram apresentados a esta Delegacia para dar continuidade aos trabalhos de polícia judiciária." (fls. 13 e 361).

Em juízo, disse que ficou na retaguarda. Foram outros dois policiais que abordaram o acusado na entrada da casa com uma sacola contendo droga. Depois disso entraram na casa e localizaram o restante da droga. Como tinham muitos galões, buscou a viatura caracterizada para conseguir leva tudo para Delegacia. Quase não coube tudo na viatura. As drogas estavam nos fundos da casa onde havia uma lavanderia. Depois de um tempo chegou uma mulher com uma criança dizendo que era esposa do acusado. Os vizinhos disseram que eles eram boas pessoas. Não se recordou quanto tempo demorou entre a apreensão das anotações e o dia em que efetuaram a diligência na casa do réu. Não foi no mesmo dia. Nos documentos apreendidos na primeira operação havia o endereço do réu escrito num papel. Esses documentos estão no outro inquérito. Na ocorrência que prendeu o réu participaram quatro policiais. Quando o réu foi abordado ele estava chegando na casa. Ele estava com uma sacola contendo pó branco. De pronto ele já começou a chorar e dizer que aquilo ia complicar ele porque ele já tinha outras passagens. A droga estava solta em pó, mas sem estar pronta para venda. A casa não tinha edícula nos fundos. A droga estava na lavanderia. Assim que entrou na lavandeira avistou a droga. Depois saiu para buscar a viatura. Tinham mais de 15 galões com o líquido. As drogas estavam em diversos lugares. Não se recordou se foi apreendido algum caderno ou anotação, mas pelo o que se lembrava, sim. O réu permitiu a entrada dos policiais porque viu que a casa tinha caído. Segundo o acusado a droga pertencia a um tal de Nenem. Mas ele não soube dar detalhes de Nenem. Os proprietários do imóvel moravam na casa de cima. Depois que estavam colocando as coisas no carro os proprietários chegaram lá. Eles disseram que os vizinhos eram gente boa.

Extrajudicialmente, a testemunha e policial civil Reginaldo Moreira declarou "que nesta data em apoio a equipe de investigação, onde em investigações referentes ao tráfico de drogas registrado no RDO 1020/2020, desta unidade policial, dentro da apreensão haviam algumas anotações da contabilidade do tráfico e endereço onde

poderia estar sendo armazenado mais drogas. Com estas informações e de comum acordo entre a equipe, deslocando até o local da investigação, permanecendo em campanha com viatura descaracterizada com vidros escuros. Momento em que observaram o indiciado chegando na casa com uma sacola. Desse modo resolveram abordar este indivíduo sendo então identificado como DIEGO COSTA BORELLI. Em revista pessoal foi encontrado na sacola que trazia consigo parte das drogas. Indagado se tinha mais drogas, confessou que nos fundos da casa estavam guardadas mais drogas, levando os policiais até o local onde foram localizados 4 tabletes de maconha; porções de cocaína e 19 galões de 5 litros com substância líquida aparentando ser lança perfume. Questionado, o indiciado disse que as drogas pertencem a um indivíduo de vulgo "NENEM", não sabendo informar seu nome ou endereço e que apenas guardava as drogas. Diante disso, o indiciado e objetos foram apresentados a esta Delegacia para dar continuidade aos trabalhos de polícia judiciária." (fls. 14 e 362).

Ouvida apenas em juízo, a informante Jéssica de Oliveira Silva, disse que era a tarde quando estava lavando o quintal de casa e quando olhou para trás tinham dois policiais na sua casa fazendo perguntas sobre o que tinha em casa e quem morava lá. Depois disso chamaram o acusado que estava brincando com o seu filho dentro da casa e começaram a vasculhar. Nos fundos da casa há uma outra casa, depois da lavandeira, onde acharam as drogas lá. Como o acusado já tinha passagens, levaram ele preso. O acusado não acompanhou a localização das drogas pelos policiais. Reviraram a casa inteira mas não acharam nada nem dentro da casa e nem na lavanderia. Morava um tal de Fabio nessa edícula. O imóvel é alugado e na época os proprietários moravam na casa de cima. Eles não presenciaram o ocorrido e nem desceram para ver o que estava acontecendo. Desde que o acusado foi preso a declarante deixou do imóvel. A declarante não foi levada à Delegacia para ser ouvida. Moravam há quase dois anos naquela casa. Era muito difícil ver o Fabio na edícula. Não soube dizer se ele efetivamente morava lá. Um mês depois que o acusado foi preso deixou o imóvel e foi morar perto da casa da sua mãe e do seu pai. Está com o acusado há quase nove anos e morando juntos há cinco ou seis anos. Nesse tempo nunca soube de nenhum envolvimento dele com tráfico de drogas ou crimes. Na fase inquisitiva, o acusado manifestou o desejo de manter-se em silêncio e pronunciar-se apenas em juízo (fls. 15 e 363).

Em juízo, o acusado negou a prática do crime. No dia dos fatos, estava em casa com sua esposa e com seu filho. Sua esposa estava lavando o corredor quando escutou algumas vozes vindo da garagem. Quando olhou viu que era policiais com arma em punho e dizendo que se tratava de uma investigação por tráfico de drogas. Eles disseram que não precisavam de mandado porque polícia civil não precisava. Eles vasculharam na sua casa mas não acharam nada. Ficou na parte da frente e não acompanhou o momento em que eles teriam encontrado as drogas que estavam numa casa que fica no fundo da lavandeira que é de outro inquilino. Viu poucas vezes esse inquilino lá porque tem uma adega e sai tarde e volta tarde do trabalho. Segundo sua esposa, os proprietários disseram que não fizeram contrato de locação com esse inquilino e ele nem deixou documentos. Salvo engano o nome desse era Julio. O declarante fez contrato de locação com os proprietários do imóvel. Os proprietários não foram arrolados como testemunha porque disseram que estava com medo. Já teve passagem por tráfico de drogas e uso de droga. Está respondendo a processo por porte de arma. Não visualizou as drogas.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas é medida de rigor.

A Defesa, em sede preliminar, arguiu que o processo padecia de nulidade, tendo em vista que os policiais que efetuaram o flagrante teriam adentrado à residência de Diego sem autorização ou competente mandado judicial.

A CF/88 prevê, em seu art. 5º, a seguinte garantia:

"XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;"

Nesse sentido, conclui-se que, havendo flagrante delito, é possível ingressar na casa mesmo sem consentimento do morador, seja de dia ou de noite.

Segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no entanto, devem existir

fundadas razões que indiquem que ali está sendo cometido um crime (flagrante delito). Nesse sentido:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas "a posteriori", que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados." (STF. Plenário. RE 603616/R0, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral - Tema 280) (Info 806))

O Superior Tribunal de Justiça também possui alguns julgados a respeito do assunto, como por exemplo:

"O ingresso regular da polícia no domicílio, sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, para que seja válido, necessita que haja fundadas razões (justa causa) que sinalizem a ocorrência de crime no interior da residência.

A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agente, embora pudesse autorizar abordagem policial em via pública para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação judicial." (STJ. 6ª Turma. REsp 1574681-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 20/4/2017 (Info 606))

Voltando aos autos, observo que os agentes públicos narraram em juízo que a diligência policial em comento foi deflagrada após a apreensão de anotações de contabilidade tráfego, constando, entre outros, o endereço mencionado na denúncia, no bojo do Boletim de Ocorrência nº 1020/2020 e do Inquérito Policial, juntamente com a apreensão de drogas no Município de Embu das Artes.

Após este fato os policiais passaram a investigar os demais endereços e realizaram campanhas na residência do acusado. O policial João Charles mencionou em juízo, inclusive, que no dia anterior ao flagrante foi realizada campanha.

Diante desse contexto, depreendo que a abordagem do réu, com uma sacola na mão contendo pó branco legitimou a atuação policial por se tratar de elementos prévios que indicavam que havia um estado de flagrância ocorrendo no local que, ainda, foram corroborados pela confissão informal do réu no sentido de que havia mais droga dentro da sua casa.

Ressalto que embora não tenham sido acostadas aos autos as anotações com os endereços apreendidos, os documentos encartados dão conta da apreensão de anotações e da existência da ocorrência anterior mencionada pelos agentes públicos ouvidos em juízo no Município de Embu das Artes.

Nesse sentido, inquestionável que havia fundadas razões da prática do tráfico ilícito de entorpecentes no interior da residência, delito de natureza permanente cuja consumação se protraí no tempo, circunstância que autorizava o ingresso dos policiais no imóvel e a realização da busca e apreensão no local, independentemente de consentimento do morador ou mandado judicial (artigo 5º, inc. XI, segunda parte, da Constituição Federal, e artigo 303 do Código de Processo Penal). Nesse sentido:

"1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protraí no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. No caso dos autos, após notícias da prática do delito, os policiais realizaram campanha no local do delito e, somente após sérios indícios da traficância, fizeram a abordagem do agente e adentraram no imóvel, onde foi efetuado o flagrante, não havendo falar em nulidade por ausência de mandado judicial" (STJ - RHC nº 120745; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; j.. 6.2.2020).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM DENEGADA" (STJ - HC nº 538256; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; j. 4.2.2020).

"2. Rejeitada a preliminar de nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de ausência de mandado judicial e invasão de domicílio. O tráfico de drogas é um crime permanente e a situação de flagrância consubstancia-se como excepcional causa que

admite a mitigação da garantia individual de inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal" (STJ - HC nº 540823; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - j. 4.2.2020).

Portanto, fica rejeitada a preliminar de nulidade arguida pela Defesa.

No que tange à titularidade dos entorpecentes, cumpre consignar que pelos relatos desinteressados dos policiais, já que nem mesmo o acusado apontou ou comprovou qualquer indício de que eles tivessem algum motivo ou interesse em acusá-lo falsamente, ficou sobejamente demonstrado que o acusado trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nesse sentido, destaco o fato do réu ter sido abordado trazendo consigo uma sacola com parte da cocaína apreendida, bem como a variedade e grande quantidade de droga encontradas na residência, a forma de acondicionamento, os petrechos, bem como a própria confissão informal do acusado, que declarou para os policiais que guardava entorpecentes para uma pessoa de vulgo Neném, provas estas que indicam que o réu detinha as substâncias com fins de traficância.

Urge mencionar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, subordinados às regras de processo penal e de direito administrativo, gozam de credibilidade e da presunção de veracidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas. No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados.

Nesse sentido:

"(...)Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)

"(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...)" (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009)

Destaco, ainda, que contrariamente do quanto alegado pela defesa, os depoimentos dos agentes públicos foram firmes, não havendo contradições a serem apontadas, diferentemente dos depoimentos prestados pela companheira do acusado, ouvida como informante, e pelo próprio réu, que sequer convergiram quanto ao nome do suposto possuidor das drogas, que morava em uma edícula nos fundos da residência do casal. Uma disse que o morador se chamava Fábio, enquanto o outro disse que era Júlio. Tendo em vista que, por ser esposa do réu, Jéssica foi ouvida como informante e, por essa razão, seu depoimento deve ser recebido com todas as ressalvas.

Além disso, o acusado não produziu nenhuma prova das suas alegações e que pudesse identificar minimamente o suposto morador da edícula, que segundo os policiais não existia, o que poderia ter sido feito a partir da oitiva dos proprietários do imóvel.

Restou evidente, portanto, que a história contada pelo réu e pela informante se deu no sentido de tentar eximir o réu de sua responsabilidade criminal.

Por outro lado, assiste razão à defesa quanto à tese de que deve haver a consunção entre os crimes do artigo 33 e 34, ambos da Lei nº 11.343/2006, respondendo o réu apenas pelo primeiro tipo penal.

O objetivo do legislador, no que tange ao crime 34, da Lei nº 11.343 de 2006, foi coibir a produção de drogas, já quanto ao delito do artigo 33, da mesma norma, impedir a sua difusão.

Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, se configura a prática dos dois delitos, em concurso material, apenas se caracterizada "a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico

tutelado de forma distinta" (AgRg no AREsp nº 303.213/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 14/10/2013). Nesse sentido, ainda:

"(...) ABSORÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO § 1º DO ARTIGO 33 E NO ARTIGO 34 PELO DO CAPUT DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. Esta Corte Superior de Justiça entende que é possível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos no § 1º do artigo 33 e no artigo 34 pelo tipificado no caput do artigo 33 da Lei 11.343/2006, desde que não caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta. 2. No caso dos autos, a autoridade apontada como coatora reconheceu que as infrações penais em apreço teriam sido práticas em contextos fáticos distintos, não havendo que se falar, assim, em aplicação do princípio da consunção. 3. Para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória providência incompatível com o rito célere do habeas corpus. Precedente. (...) (STJ - HC 346077 / SP; QUINTA TURMA; Rel. Ministro JORGE MUSSI; j. 17/05/2016)

"DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MAQUINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. ARTS. 33, 34 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DECOTE DE CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA DE REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA MESMA LEI. PLEITOS INVIÁVEIS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS NORMAS VIOLADAS. RECURSO ESPECIAL COM MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 2. PEDIDOS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPROPRIEDADE DA PROVIDÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA NOS ARTS. 33 E 34 DA LEI N. 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. POSSE E INSTRUMENTOS. CRIME MEIO. 4. BALANÇA DE PRECISÃO E SERRA CIRCULAR. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. OBJETOS PRÓPRIOS DO CRIME DE TRÁFICO. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...) 3. Há nítida relação de subsidiariedade entre os tipos penais descritos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006. De fato, o tráfico de maquinário visa proteger a "saúde pública, ameaçada com a possibilidade de a droga ser produzida", ou seja, tipifica-se conduta que pode ser considerada como mero ato preparatório. Portanto, a prática do art. 33, caput, da Lei de Drogas absorve o delito capitulado no art. 34 da mesma lei, desde que não fique caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta. No caso, referida análise prescinde do reexame de fatos, pois da leitura da peça acusatória, verifica-se que a droga e os instrumentos foram apreendidos no mesmo local e num mesmo contexto, servindo a balança de precisão e a serra/alicate de unha à associação que se destinava ao tráfico de drogas, não havendo a autonomia necessária a embasar a condenação em ambos os tipos penais simultaneamente, sob pena de bis in idem. 4. Salutar aferir, ademais, quais objetos se mostram aptos a preencher a tipicidade penal do tipo do art. 34 da Lei de Drogas, o qual visa coibir a produção de drogas. A meu ver, deve ficar demonstrada a real lesividade dos objetos tidos como instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sob pena de a posse de uma tampa de caneta - utilizada como medidor -, atrair a incidência do tipo penal em exame. Relevante, assim, analisar se os objetos apreendidos são aptos a vulnerar o tipo penal em tela. No caso dos autos, além de a conduta não se mostrar autônoma, verifico que a apreensão de uma balança de precisão e de um alicate de unha não pode ser considerada como posse de maquinário nos termos do que descreve o art. 34 da Lei de Drogas, pois referidos instrumentos integram a prática do delito de tráfico, não se prestando à configuração do crime de posse de maquinário. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para excluir a condenação dos recorrentes Márcia Regina Millezi e Francisco Luís Alves de Lima pela prática do delito do art. 34 da Lei de Drogas." (STJ - RESp 1196334 / PR; QUINTA TURMA; Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE; j. 19/09/2013)

No caso, mostrou-se evidente que os entorpecentes e os petrechos supracitados foram apreendidos dentro do mesmo contexto fático, isto é, no mesmo momento e local, a indicar que pertenciam à mesma linha da cadeia produtiva (a droga que estava ali foi preparada/produzida/transformada por meio dos petrechos apreendidos), sendo

meios necessários para a prática do crime de tráfico de drogas, não atingindo, de forma autônoma e distinta, o bem jurídico tutelado.

Assim, de rigor a aplicação do princípio da consunção de forma que o crime capitulado no artigo 34 da Lei de Drogas deve ser absorvido por aquele previsto no artigo 33, caput, da mesma Lei.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória apenas em relação ao crime de tráfico de drogas

Passo a dosar a reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o réu possui outra condenação com trânsito em julgado que configura mau antecedente conforme processo nº 0005038-34.2008.8.26.0609, registrado na certidão de antecedentes de fls. 158/159, de modo que majoro a pena em 1/6); conduta social (nada a ser valorado); personalidade (não há elementos para aferir eventual personalidade nociva do réu); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (tendo em vista que, além das drogas, no mesmo contexto foram encontrados com o acusado petrechos para preparação do entorpecente à venda, tais como balanças, peneiras, liquidificador e invólucros plásticos e de vidro, a demonstrar que o acusado praticava múltiplas atividades relacionadas ao tráfico de drogas, aumento a pena em 1/6); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar); quantidade da droga (considerando que o acusado foi surpreendido com expressiva quantidade e diversidade de drogas, dividida em 3.039g (três mil e trinta e nove gramas) de "maconha", acondicionada em 04 (quatro) tabletes, na massa líquida de 13.420g (treze mil, quatrocentos e vinte gramas) de cocaína e em 95 (noventa e cinco) litros de lança perfume – suficientes para sustentar o vício de grande quantidade de pessoas, aumento a pena do acusado em 1/2); natureza da droga (tendo em vista que as investigações demonstraram que o réu traficava cocaína, lança perfume e maconha, e considerando que numa escala de ofensividade o crack está à frente da cocaína que, por sua vez, está à frente da maconha, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade de majorar em 1/4 quando se tratar de crack e em 1/6 quando se tratar de cocaína, não merecendo majoração quando se tratar de maconha. Portanto, valoro essa circunstância negativamente em 1/6).

Assim, fixo a pena base no dobro ($1/6+1/6+1/6+1/2$) acima do mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não verifico a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, diante do mau antecedente do réu.

Assim, torno definitiva a pena para o crime de tráfico de drogas em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 c/c art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal c/c o artigo 42, da Lei 11.343/06, considerando que a pena supera os 08 (oito) anos de reclusão, bem como se tratar de crime equiparado a hediondo e pelas circunstâncias negativas atinentes ao crime de tráfico drogas, especialmente a quantidade e natureza da droga, bem como a apreensão de petrechos.

Em que pese a resolução nº 5 do Senado Federal, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos uma vez que a pena aplicada supera os quatro anos e acusado é reincidente.

Também não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da ação penal, e assim o faço para:

a) CONDENAR o réu DIEGO COSTA BORELLI ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e
b) ABSOLVER o réu DIEGO COSTA BORELLI do crime capitulado no artigo 34, da Lei nº 11.343/06, imputado na denúncia, ante a aplicação do princípio da consunção, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.

Estando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à prisão preventiva do acusado, agora reforçados pela certeza acerca da materialidade e autoria, conforme fundamentado acima, indefiro o direito do réu recorrer em liberdade.

Expeça-se guia de execução provisória.

Transitado em julgado: a) expeçam-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e do artigo 63 da Lei de Drogas, DETERMINO O PERDIMENTO em favor da União dos seguintes bens que foram formalmente apreendidos nos autos, que deverão ser revertidos ao FUNAD: (i) os petrechos utilizados na preparação e fabricação de substâncias entorpecentes. Em relação aos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes apurados nestes autos e que foram formalmente apreendidos, OFICIE-SE à Autoridade Policial para que inicie o procedimento previsto no artigo 61 e seus parágrafos da Lei nº 11.343/06 em autos apartados. Com a resposta da Autoridade Policial, dê-se vista ao Ministério Público e, após, voltem conclusos.

Custas ex legis.

P. I. C.

Taboão da Serra, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA